

1507680-42.2022.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507680-42.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507680-42.2022.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104381/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 24342993 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2104381 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ALAN DE SOUZA DOURADO e ELVIS NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS na qual lhes imputam a prática de infração penal positivada no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, em concurso material, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Narra-se a denúncia que “no dia 15 de abril de 2022, por volta das 19h00min, na Rodovia, próximo da Chácara Boa Esperança, bairro Reforma Agrária, nesta cidade e comarca de Valinhos, ALAN DE SOUZA DOURADO, menor de 21 anos de idade no dia do

crime, e ELVIS NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS, menor de 21 anos de idade no dia do crime, e outro indivíduo não identificado, com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima Fabricio Martins Dias, o veículo VW/Polo MCA, placa EUG8179 - Valinhos/SP, 01 telefone celular, marca Iphone 8 Plus, 04 cartões bancários, a carteira e documentos pessoais da vítima. Consta que, em seguida, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ALAN DE SOUZA DOURADO e ELVIS NASCIMENTO, e outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, Fabricio Martins Dias, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a fazer, consistente em fornecer as senhas dos cartões bancários e do aplicativo Icloud, a fim de realizarem saques de dinheiro e efetuar transações bancárias em nome do ofendido."

A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2022 (fls. 87/89).

Devidamente citado em 14 de junho de 2022 (fls. 108), o acusado Alan de Souza Dourado apresentou resposta à acusação a fls. 132.

Devidamente citado em 30 de junho de 2022 (fls. 136), o acusado Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos apresentou resposta à acusação a fls. 142/147.

Não constatada hipótese de absolvição sumária (fls. 155/158), designou-se audiência de instrução e julgamento, realizada em 12 de setembro de 2022, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se aos interrogatórios (fls. 213/214). Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação de Alan de Souza Dourado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pugnou, ainda, pela absolvição de Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos, em razão da ausência de prova suficiente da autoria delitiva.

As defesas técnicas dos acusados apresentaram suas razões finais oralmente, requerendo a absolvição dos acusados.

Decisão prolatada em audiência determinou a revogação da prisão preventiva de Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos (fls. 213/214).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, em concurso material, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07 e fls. 25), pelo boletim de ocorrência (fls. 38/40), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 26), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, necessário que sejam tecidas considerações individuais em relação

aos réus. De antemão, aponto que há provas robustas e suficientes da autoria delitiva de Alan de Souza Dourado, mas não em relação a Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos.

Em solo policial (fls. 22/23), a vítima Fabricio narrou que (a) trabalha como motorista de aplicativo e, após deixar uma passageira no bairro Reforma Agrária, procedeu a um retorno em um túnel, avistando um veículo Ford/Ká que vinha em alta velocidade pelas costas da vítima, (b) o automóvel em apreço, ao realizar a curva, ultrapassou o veículo conduzido por Fabricio, parando em sua frente, impedindo-o de prosseguir em sua rota, (c) desceram dois indivíduos armados do veículo Ford/Ka, tendo um deles assumido a direção do automóvel VW/Polô conduzido pela vítima, e o outro permaneceu com Fabricio, no banco traseiro, apontando uma arma em sua cabeça, (d) os acusados permaneceram com a liberdade cerceada por cerca de 40 minutos, (e) em dado momento, os dois sujeitos pararam em local desconhecido, se encontrando com um terceiro indivíduo, (f) após conversarem com mencionado sujeito, retornaram ao veículo e exigiram que a vítima lhes passasse as senhas dos cartões bancários e do iCloud, tendo Fabricio cumprido as exigências, (g) momentos depois, os indivíduos abandonaram a vítima no bairro Campo Belo, onde conseguiu auxílio e acionou a Polícia Militar.

Ouvido em juízo, a vítima Fabricio confirmou a narrativa prestada em sede policial. Acrescentou, ainda, que (a) reconhece apenas um dos indivíduos que participou da empreitada criminosa, aquele que tomou a direção de seu veículo, (b) apontou tal indivíduo como sendo Alan, em reconhecimento judicial, (c) em relação ao sujeito que permaneceu no banco traseiro do veículo, não consegue identificá-lo, pois estava de máscara e com o capuz da blusa sobre a cabeça. Saliento que à vítima foi apresentado o réu Elvis, não o tendo reconhecido como autor dos fatos, ressaltando que “nunca o viu na vida”.

Ouvida em solo policial (fls. 12), a testemunha Wellington Pereira Romão, policial militar, declarou que (a) faz parte da equipe tática da Polícia Militar, estando em patrulhamento no momento do crime, se dirigindo ao local do último avistamento do veículo, (b) ato contínuo, encontraram o automóvel de emplacamento EUG8179, abordando seu condutor, identificado como Alan, que foi posteriormente reconhecido pela vítima como um dos roubadores, (c) revistado, foi encontrado na posse de Alan o aparelho celular da vítima e sua carteira, (d) o autuado confessou aos militares que cometeu os crimes imputados com Elvis, que havia se dirigido até sua casa para guardar as armas, (e) os policiais se deslocaram até a residência de Elvis, mas ele não foi encontrado. Em juízo, confirmou a versão apresentada anteriormente, acrescentando que chegaram a se deslocar até o suposto endereço de Elvis, não o encontrando no local, mas apenas sua companheira à época. Ainda, disse que não chegou a ter qualquer contato com Elvis, e não sabe quais diligências foram realizadas pela Polícia Civil no sentido de demonstrar sua participação no crime.

Ouvida em solo policial (fls. 20/21), a testemunha Ana Claudia Alves Ferreira, policial militar, disse que (a) estava em patrulhamento quando recebeu chamado via Copom para averiguação de um crime de roubo, tendo se deslocado às imediações do delito, momento em que os militares avistaram o veículo de emplacamento EUG8179, com um indivíduo dentro, (b) abordaram o sujeito, identificado como Alan, que trazia em sua posse o aparelho celular e a carteira da vítima, (c) Alan relatou aos milicianos que havia cometido o delito juntamente com Elvis, indicando o local onde este reside, dizendo que o comparsa havia se dirigido à sua casa para guardar as armas utilizadas, (d) os militares se deslocaram ao endereço de Elvis, mas não o encontraram, (e) a vítima reconheceu Alan pessoalmente, e Elvis por meio fotográfico. Em juízo, confirmou os fatos anteriormente declarados, acrescentando que obtiveram um documento de Elvis com a suposta companheira dele à época, e entregaram à Polícia Civil. Afirmou, ainda, que não procedeu ao reconhecimento fotográfico de Elvis, tendo sido realizado pela Polícia Civil.

Em solo policial (fls. 13), o acusado Alan de Souza Dourado se valeu de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ouvido em sede judicial, alegou que (a) os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, com exceção dos relatos em relação a Elvis, pois este não participou da empreitada criminosa, (b) à época, residia no município de Salto, e combinou com dois indivíduos de realizarem um assalto, (c) a arma de fogo utilizada não era verdadeira, mas apenas um simulacro, (d) a princípio, sua participação na empreitada criminosa se restringiria a conduzir o veículo automotor, não tendo consciência de todo o desenrolar do plano.

Em juízo, o acusado Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos alegou que (a) não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, (b) no dia do crime estava trabalhando como pintor, juntamente com seu pai, (c) já foi abordado diversas vezes pelos policiais que prestaram depoimento em juízo, (d) conhece Alan, mas não tem nenhuma relação próxima com ele, não sabendo por qual razão foi colocado nesta situação.

Diante dos depoimentos colacionados acima, resta clara a autoria de Alan na empreitada criminosa, juntamente com dois outros indivíduos. Ocorre que em relação a Elvis, não há qualquer prova que aponte sua participação no delito. A vítima não o reconheceu, os policiais militares tão somente disseram que Alan, no momento da prisão em flagrante, relatou que Elvis era um dos participantes do roubo. Ocorre que este relato, isoladamente, não é suficiente para embasar a condenação de Elvis. Saliento, ainda, que o próprio órgão acusatório pugnou pela absolvição de Elvis.

Quanto à autoria de Alan, não há controvérsia mínima. A vítima já havia reconhecido o acusado pessoalmente em sede policial, e novamente o identificou como um dos indivíduos que o abordou. Ademais, Alan confessou a prática dos crimes descritos na peça acusatória.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, os fatos praticados preenchem todas as elementares dos tipos penais imputados na denúncia. Explico.

Restou cabalmente demonstrado que Alan, ora acusado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, com unidade de designios, abordaram o veículo da vítima Fabricio, com armas de fogo em punho, obrigando-o a parar. Ato contínuo, Alan adentrou no veículo, no assento do motorista, enquanto um comparsa permaneceu no banco traseiro do veículo, juntamente com a vítima, apontando-lhe uma arma, e traficaram sob essas condições por cerca de 40 minutos.

Além da subtração da carteira e celular de Fabricio, o acusado Alan e seus comparsas ainda exigiram o desbloqueio de seu aparelho celular e do sistema Icloud, ainda obrigando-o a fornecer as senhas dos cartões bancários, tudo sob constante ameaça.

Há subsunção dos fatos a dois delitos distintos. O primeiro consiste naquele previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, Código Penal, consistente na subtração de coisa alheia móvel (carteira e celular da vítima), mediante grave ameaça à pessoa, em concurso de duas ou mais pessoas, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

O segundo delito cometido está tipificado no artigo 158, parágrafos 1º e 3º, Código Penal, consistente no constrangimento da vítima, mediante grave ameaça, a fazer alguma coisa (desbloqueio do aparelho celular, Icloud com as senhas salvas e fornecimento das senhas dos cartões de crédito), com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica e, ainda, mediante concurso de duas ou mais pessoas, com restrição de liberdade da vítima. Trata-se de modalidade qualificada de extorsão, crime este de natureza formal, que se consuma “com o constrangimento da

vítima, diante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida". Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL ALIADO A OUTROS MEIOS DE PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE FORNECEU SENHAS DE SEUS CARTÕES BANCÁRIOS E TEVE A RESTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE SOB AMEAÇA DE SUPOSTA ARMA DE FOGO ENQUANTO ERAM REALIZADOS SAQUES EM SUA CONTA BANCÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. INVIABILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- O delito descrito no art. 158, § 3º, do Código Penal é formal, restando configurado apenas com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida. Na espécie, a obtenção da vantagem - saques realizados - configurou o exaurimento do crime. Nesse contexto, o fato de a vítima haver fornecido as senhas de seus cartões bancários e de crédito, depois de haver sido abordada e mantida em seu veículo pelo paciente, sendo ameaçada com o uso de suposta arma de fogo, enquanto o corréu realizava saques em sua conta bancária, caracteriza o crime de extorsão qualificada, o qual não se confunde com a modalidade simples do delito. Precedentes.

- O entendimento exarado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC n. 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020).

Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido."

(STJ. QUINTA TURMA. AgRg no HC 693380/SP, rel. Min REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 28 de setembro de 2021, destacado).

Mostra-se relevante salientar, ainda, que a causa de aumento consistente no concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 158, parágrafos 1º, CP) é compatível com a modalidade qualificada da extorsão (art. 158, parágrafos 3º, CP) e, portanto, será devidamente considerada quando da dosimetria da pena. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DAS ALEGAÇÕES. ARTS. 157, § 2.º, INCISO II, § 2.º-A, INCISO I, E 159, § 1.º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O TIPO DO ART. 158, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. OFENDIDO CONSTRANGIDO A COLABORAR COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDIÇÃO OU PREÇO DO RESGATE EXIGIDOS A TERCEIRO. MAIS DE UM SUJEITO PASSIVO. APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 158, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO CONSUMADO COM O CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA. DOSIMETRIA DO ROUBO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E QUANTUM PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO ROUBO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA

CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...)

- Ficou explicitado, na narrativa fática firmada na origem, que o delito de extorsão foi praticado por vários agentes e com o emprego de armas, hipótese em que é aplicável a causa de aumento do art. 158, § 1.º, do Código Penal, a qual é compatível com a forma qualificada da extorsão do art. 158, § 3.º, do Código Penal (REsp n. 1.353.693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

(...)

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para desclassificar a condenação do ora paciente pelos crimes dos arts. 157, § 2.º, inciso II, § 2º-A, inciso I e 159, § 1.º, do Código Penal, para os delitos dos arts. 157, § 2.º, inciso II, § 2º-A, inciso I e 158, § 1º e 3.º, do Código Penal, e determinar que o Tribunal a quo proceda ao refazimento da dosimetria das penas do paciente, tomando como base a nova classificação típica da extorsão, mantidos os demais termos da condenação."

(STJ. QUINTA TURMA. HC 622604/SP, rel. Min. REYNALDO FONSECA SOARES, j. em 21 de setembro de 2021, destacado).

Por fim, insta consignar que os crimes foram praticados em concurso material, pois "mediante mais de uma ação ou omissão, [o agente] praticou mais de uma ação ou omissão", fazendo incidir a regra positivada no art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas aplicadas. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente"

(AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020).

Agravo regimental desprovido."

(STJ. QUINTA TURMA. AgRg no REsp 1931204/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, j. em 18 de maio de 2021, destacado).

Por fim, quanto à alegação do acusado Alan, no sentido de que se utilizou de simulacro de arma de fogo na empreitada criminosa não é apta a afastar a causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, Código Penal. Isso porque não houve a apreensão do objeto para verificação de sua aptidão em efetuar disparos. A simples alegação do réu não é suficiente para tanto. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento

dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despcienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ. QUINTA TURMA. AgRg no HC 720951/MS, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. em 29 de março de 2023, destacado).

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI). Por razões organizacionais, a dosimetria da pena do acusado Alan de Souza Dourado será realizada separadamente por cada crime.

- Artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, Código Penal:

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada.

Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 209 aponta a primariedade e bons antecedentes do acusado. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, constato duas circunstâncias que devem ser valoradas negativamente, a saber: (i) o fato de que eram três os indivíduos que praticaram o crime em apreço, embora dois deles não tenham sido identificados. Não há que se falar em bis in idem em relação à causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas, pois esta exige tão somente duas pessoas para sua incidência. Ainda, conforme será fundamentado à frente, não haverá a consideração desta causa de aumento na aplicação da pena; (ii) o fato de que os roubadores utilizaram duas armas de fogo na prática do delito, causando maior temor e risco à incolumidade física e psíquica das vítimas. Além disso, apontavam os artefatos ostensivamente no rosto das vítimas. Também não há que se falar em bis in idem, pois para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo basta a utilização de apenas uma, enquanto no presente caso foram empregadas duas.

Os motivos e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg

no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, no caso, não incidem agravantes. Há, no entanto, a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), bem como a atenuante relacionada à idade do agente à época dos fatos, que contava com 18 anos de idade (art. 65, I, CP). Assim, fixa-se a pena provisória em 03 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 55 dias-multa.

Na terceira fase, incidem três causas de aumento, consistentes no emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplico tão somente uma delas, a mais grave, consistente no emprego de arma de fogo (art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, CP), no patamar de 2/3. Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 91 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a pena tenha sido fixado em patamar inferior a 08 anos de reclusão, as circunstâncias consideradas quando da aplicação a pena, extremamente reprováveis e negativas, recomendam o regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, Código Penal.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas pelas circunstâncias judiciais extremamente negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do

regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

- Artigo 158, parágrafos 1º e 3º, Código Penal:

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada.

Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 209 aponta a primariedade e bons antecedentes do acusado. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, constato duas circunstâncias que devem ser valoradas negativamente, a saber: (i) o fato de que eram três os indivíduos que praticaram o crime em apreço, embora dois deles não tenham sido identificados. Não há que se falar em bis in idem em relação à causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas, pois esta exige tão somente duas pessoas para sua incidência; (ii) o fato de que os criminosos utilizaram duas armas de fogo na prática do delito, causando maior temor e risco à incolumidade física e psíquica das vítimas. Além disso, apontavam os artefatos ostensivamente no rosto das vítimas. Também não há que se falar em bis in idem, pois para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo basta a utilização de apenas uma, enquanto no presente caso foram empregadas duas.

Os motivos e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério,

cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 98 dias-multa.

Na segunda fase, no caso, não incidem agravantes. Há, no entanto, a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), bem como a atenuante relacionada à idade do agente à época dos fatos, que contava com 18 anos de idade (art. 65, I, CP). Assim, fixa-se a pena intermediária em 05 anos de reclusão, mais o pagamento de 55 dias-multa.

Na terceira fase, incide uma causa de aumento, consistentes no empenho de arma de fogo e concurso de agentes. A causa de aumento em apreço tem intervalo de 1/3 até metade. Tendo em vista a ausência de maiores elementos aptos à exasperação acima do patamar mínimo, me utilizo deste nesta derradeira etapa. Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 73 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a pena tenha sido fixado em patamar inferior a 08 anos de reclusão, as circunstâncias consideradas quando da aplicação a pena, extremamente reprováveis e negativas, recomendam o regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, Código Penal.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas também pelas circunstâncias judiciais negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Em observância ao disposto no art. 69 do Código Penal, na hipótese de concurso material de crimes – como o caso ora analisado, nos termos da fundamentação supra

-, as penas devem ser somadas. Nesses termos, fica a pena definitiva de Alan de Souza Dourado fixada em 15 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 243 dias-multa.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de: (a) ABSOLVER o acusado ELVIS NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS da acusação que lhe foi feita pela prática dos delitos descritos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, V, Código de Processo Penal; (b) CONDENAR o acusado ALAN DE SOUZA DOURADO ao cumprimento de 12 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 164 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), em razão da prática dos crimes descritos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, em concurso material, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Quanto à manutenção da prisão cautelar de Alan de Souza Dourado, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

A título de observação, consigno que o acusado Elvis Nascimento Rodrigues dos Santos teve a prisão preventiva revogada quando da realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente expedido o alvará de soltura e cumprido (fls. 232).

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Custas pelos réus (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Valinhos, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA